

1501644-73.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/10/2022

... seccional no local para combate ao tráfico de drogas. O local é conhecido ponto de tráfico. Disse que visualizou o acusado em atitude suspeita. Decidiu pela abordagem, e com ele foi encontrada certa quantidade de drogas (maconha) e R\$ 15,00 em dinheiro. Disse que ele admitiu que estava praticando o tráfico, e indicou o local em que havia mais drogas. Não acompanhou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501644-73.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501644-73.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2210760/2022 - SIG

DEL.SEC.DIADEMA, EL8000/2022 - SIG DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MESAQUE FREITAS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

MESAQUE FREITAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 11h15, na Avenida marginal Z, n.º 100, bairro Conceição, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo e guardava, para o consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 24 invólucros plásticos contendo cocaína, 56 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, e 47 invólucros plásticos contendo cannabis sativa L, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica. O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 75/77.

O réu foi regularmente notificado, tendo apresentado defesa preliminar a fls. 81/83. A denúncia foi recebida a fls. 84/85, e o réu foi regularmente citado (fls. 110).

Na audiência de instrução debates e julgamento foi colhida a prova oral. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de

gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, não verifico situação de nulidade das provas por suposta ilegalidade na atuação dos policiais. Como se sabe, nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso dos autos, entendo que tais requisitos legais foram cumpridos.

Com efeito, trata-se de hipótese envolvendo uma operação policial em curso ("Operação Sufoco"), direcionada a conhecido ponto de tráfico de drogas. O acusado estava parado neste local e demonstrou inquietude com a presença das viaturas, circunstâncias que, em conjunto, motivaram a abordagem policial. Não se trata, portanto, de hipótese de busca pessoal realizada de forma aleatória e indiscriminada em pessoas escolhidas a esmo em via pública, mas abordagem de pessoa em atitude suspeita em ponto de tráfico. Este contexto afasta a aplicação dos precedentes indicados pela Defensoria Pública em alegações finais.

A respeito, em caso assemelhado, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (...) III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2.º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada (...) (STJ, AgRg no HC 684062/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuino Rissato, DJe de 03/11/2021).

Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade da atuação policial, não sendo hipótese de incidência dos precedentes indicados pela Defensoria Pública.

Superada a questão, pelo mérito a presente ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 75/77, que atestou positivo para as substâncias entorpecentes tetrahydrocannabinol (THC - maconha) e cocaína, substâncias estas consideradas ilícitas pela Portaria 344/1998 SVS/MS. Consigno que a perícia não foi contestada pela defesa.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo. É certo que de acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Em juízo, a testemunha Denis Fabrício Paiola Monzani, policial civil, afirmou que no dia dos fatos havia diligência pela seccional no local para combate ao tráfico de drogas. O local é conhecido ponto de tráfico. Disse que visualizou o acusado em atitude suspeita. Decidiu pela abordagem, e com ele foi encontrada certa quantidade de drogas (maconha) e R\$ 15,00 em dinheiro. Disse que ele admitiu que estava

praticando o tráfico, e indicou o local em que havia mais drogas. Não acompanhou o depoimento do acusado em delegacia. Questionado, disse que com o acusado havia cerca de 5 porções de maconha. As demais drogas (cocaína, crack e maconha) estavam escondidas no mato. Disse que apenas encontrou as drogas a partir da indicação feita pelo próprio acusado.

A testemunha Bruno Becker, policial civil, ouvido em juízo, confirmou o depoimento de Denis. Disse que estava em operação, e foi até o local que é conhecido ponto de venda de drogas. Afirmou que viu o acusado parado neste local, e decidiu pela abordagem. Com ele foi encontrada pequena quantidade de drogas. O acusado indicou o local em que estavam mais drogas. Disse que é praxe dos traficantes do local deixarem uma pequena quantidade de drogas consigo e as demais drogas escondidas. Observe-se que os depoimentos prestados em juízo por estes policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, sobretudo porque seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP – STF).

Deve-se ressaltar que o réu, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial confessou integralmente a prática delitiva.

Em juízo o acusado disse que não trabalha, e que mora com sua mãe e mulher.

Confessou a prática delitiva. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, e decidiu então “trabalhar” no tráfico naquele dia. Afirmou que trabalhava anteriormente como ajudante de pedreiro, mas não estava conseguindo emprego.

Ora, nos termos do art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso dos autos, o local em que ocorreu a prisão (conhecido ponto de tráfico de drogas), a forma como estava embalada a droga, a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, o encontro de dinheiro e o resultado da observação prévia feita pelos policiais (identificando o acusado parado no local, em atitude suspeita) são indicativos do intuito de traficância. Por outro lado, pela própria quantidade e demais circunstâncias, não há como desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistirem pacificamente em uma única pessoa.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira “lei do silêncio”, por temer sofrer represálias.

Neste contexto, a prova dos autos demonstra que no dia dos fatos, policiais civis realizavam diligências quando se depararam com o denunciado em atitude suspeita que, ao avistar a viatura, mostrou-se inquieto, motivando a abordagem. Em revista

peçoal, os policiais encontraram com o denunciado 05 porções de maconha, além da quantia de R\$ 44,00. Indagado, o denunciado admitiu aos agentes que estava comercializando os entorpecentes e indicou onde estava guardado o restante das drogas. No local apontado, mais precisamente em uma vegetação próxima ao local da abordagem, os policiais encontraram uma pochete contendo 24 porções de cocaína, 56 de crack e 42 de maconha, todas embaladas e individualizadas. Em solo policial, o denunciado confessou a traficância e esclareceu, inclusive, por quanto vendia cada porção da droga (fls. 08). Em Juízo, tornou a confessar a prática delitiva. A finalidade de tráfico restou devidamente demonstrada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, forma de seu acondicionamento, assim como, pelo local dos fatos, pelo valor em espécie apreendido e pelas condições em que se desenvolveu a ação.

Não há dúvidas de que o comportamento do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1.<sup>a</sup> T. - HC n.º 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p. 11.012).

Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Ressalto que o argumento de que o acusado praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão.

Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu:

"Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar e lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.<sup>a</sup> Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

É o que basta para a caracterização do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Comprovada, assim, a autoria e a materialidade do delito. Impõe-se, nestes termos, a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, seguindo os critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, deve ser considerada como circunstância judicial preponderante desfavorável a natureza das drogas apreendidas, dentre elas a cocaína, substância que notoriamente vulnera de forma mais intensa o bem jurídico protegido - qual seja, a saúde pública -, causando maior grau de dependência do que outras drogas ilícitas, como a maconha. Anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.<sup>a</sup> ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286, grifei). Significa dizer que o legislador explicitou, no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que já deveram ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59, do Código Penal, transformando-as em preponderantes.

Desta forma, a pena base deve ser agravada em 1/6, sendo fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo, considerando as condições econômicas do réu.

Na segunda fase da dosimetria, o acusado ostenta condenação anterior com trânsito em julgado para a defesa, o que autoriza o reconhecimento da reincidência, eis que

o recurso interposto pelo Ministério Público nos autos do processo n.º 1501937-77.2022 visa, apenas, a elevação da pena. Não obstante, esta circunstância agravante deve ser compensada com a confissão. Entendo que a confissão demonstra aspecto positivo da personalidade do agente, de modo que deve ser considerada circunstância preponderante, nos termos do art. 67, do Código Penal. Neste sentido: "A confissão espontânea tem caráter preponderante, compensando a reincidência (...)" (STF, 2.ª T., HC 101.909, rel. Min. Ayres Britto, j. 28.2.2012). E ainda: "Militando em favor do agente a atenuante da confissão espontânea e, em seu desfavor, a agravante da reincidência, ambas preponderantes da dicção do art. 67 do Código Penal, devem essas se compensar ou se anular" (TJMG, Apelação 1.0024.10.060862-9/001, j. 29.3.2011).

Na terceira fase da dosimetria, não vislumbro a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006. Isto porque, para incidência do referido dispositivo legal, é necessário o concurso simultâneo de quatro circunstâncias, quais sejam: (i) que o agente seja primário, (ii) de bons antecedentes, (iii) não se dedique às atividades criminosas e (iv) nem integre organização criminosa. Ora, no caso dos autos, o acusado ostenta condenação anterior com trânsito em julgado para a defesa. Embora se trata de ação penal ainda em curso (pois pendente apreciação de recurso interposto exclusivamente pela acusação), tal circunstância autoriza o afastamento do Tema n.º 1139, por se tratar de hipótese de distinguishing.

Diante disto, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais ao pagamento de 583 dias-multa.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do habeas corpus n.º 111.840-ES (Informativo STF n.º 507), ser inconstitucional a fixação obrigatória de regime inicial fechado, consoante dispõe o § 1.º, art. 2.º, da Lei n.º 8.072/90, com as alterações decorrentes da Lei n.º 11.464/07. Assim, de acordo com referido precedente, compete ao juiz, analisadas as especificidades do caso concreto, fixar o regime inicial de cumprimento de acordo com as disposições do art. 33, do Código Penal.

Este mesmo entendimento deve ser aplicado no caso em tela, quer pela chamada "objetivação do controle difuso" (tese adotada e aplicada pelo E. Supremo Tribunal Federal), quer em sede de controle difuso de constitucionalidade por este Magistrado, declarando-se a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do dispositivo legal em comento. De fato, a fixação a priori, pelo legislador, de um regime inicial de cumprimento, sem permitir que o Magistrado possa aferir, no caso concreto, qual o regime mais adequado para o sentenciado, com análise dos requisitos objetivos e subjetivos, fere o princípio implícito da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5.º da CF/88). Partindo destas premissas, passo a fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Considerando a quantidade de pena estabelecida e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (consoante fundamentação acima), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, observados os termos do art. 33, § 3.º, do CP. Consigno que à vista das especificidades do caso concreto, considerando a diversidade das drogas e a traficância de substâncias que causam uma maior dependência química, a fixação de regime inicial diverso não seria suficiente para a reprovação e prevenção da conduta. Ademais, a fixação deste regime inicial não fere o disposto no art. 33, § 3.º, que estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal. Ocorre que conforme fundamentação acima, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, a despeito de estarem evidenciadas no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006 como preponderantes, também são circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59, do Código Penal.

No que se refere à aplicação do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, verifico que diante da quantidade de pena estabelecida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso, ainda que considerado o tempo da prisão preventiva. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código

de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei).

De fato, raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o juízo das execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese os termos da Resolução n.º 05, do Senado Federal, não estão presentes os requisitos autorizadores à substituição da pena por restritiva de direitos, notadamente pela quantidade de pena estabelecida.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar MESAQUE FREITAS DOS SANTOS qualificado nos autos, à pena 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Mantenho a prisão preventiva do acusado. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. Trata-se de crime equiparado a hediondo. A manutenção da prisão evitará a reiteração da conduta criminoso, levando-se em conta o fato de que se trata de reincidente específico. Por tal razão, mantenho a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos das decisões proferidas nestes autos, adotando-as como razão de decidir. Expeça-se mandado de prisão, de acordo com as NSCGJ, se necessário.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei n.º 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária. Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006. Decreto a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado:

a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

Não havendo interesse na preservação do bem apreendido (auto de apreensão de fl. 22, pochete), e considerando a ausência de valor econômico, autorizo sua destruição.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Diadema, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA